

1501704-76.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... vazios, caderneta e agenda com anotações do tráfico, e a confissão informal do réu aos policiais militares, estão a caracterizar a traficância.

No caso, não se pode olvidar que foram apreendidas duas balanças de precisão, eppendorfs vazios, plástico filme, papel alumínio, caderneta e agenda com anotações do tráfico, juntamente com as drogas, o que só vem reforçar que ali ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501704-76.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501704-76.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2333032/2021 - 01º D.P. BIRIGUI, 21822343 - 01º D.P.

BIRIGUI, 2333032 - 01º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DIEGO LINO DUTRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1501704-76.2021.8.26.0603 (Controle nº 2482/2021)

VISTOS.

WESLEY DIEGO LINO DUTRA, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput,

da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 12h05, à Rua Joaquim Cicilliati, nº 2.000, Residencial Monte Líbano, nessa cidade e Comarca de Birigui, trazia consigo 03 (três) frascos de lança-perfume e 10,15 (dez gramas e quinze centigramas) de maconha e guardava 8,65 gramas (oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína, 46,08 gramas (quarenta e seis gramas e oito centigramas) de crack, 50,54 gramas (cinquenta gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína, 815,94 (oitocentos e quinze gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 34 (trinta e quatro) frascos de lança-perfume, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de constatação prévia de fls. 24/26, 27/29, 30/32, 33/35, 36/38 e exames toxicológicos de fls. 133/135, 136/138, 139/141, 142/144, 145/147, 348/350 e 353/355.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 170), cuja peça foi juntada às fls. 243/259, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 24 de maio de 2022 (fls. 283/284) e a citação do acusado à fl. 310.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 339/340).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 359/267).

A defesa, por sua vez, requer a absolvição do acusado, alegando inexistência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal; a aplicação do artigo 33 § 4ª da Lei 11.343/2006; o reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa; fixação do regime aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito do réu recorrer em liberdade (fls. 370/386).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fl. 01); o recibo de entrega de preso (fl. 02); o boletim de ocorrência (fls. 07/11); a nota de culpa (fl. 45); o relatório final (fls. 148/149); os laudos de constatação prévia (fls. 24/38); os laudos periciais (fls. 133/147, 172/191, 348/350 e 353/355); os depoimentos das testemunhas; e a as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia, o acusado disse estava com dois amigos, Renato e Luis Gustavo, para usar drogas juntos, quando a polícia militar os abordaram. Estava com três frascos de lança-perfume e duas porções de maconha. Após, dirigiram-se a sua residência, onde foram encontrados mais entorpecentes. Afirmou que era tudo para seu consumo. O caderno, agenda e balanças apreendidos eram seus (fl. 07).

Em juízo, o acusado relatou que os entorpecentes encontrados com ele eram para seu consumo. Foi obrigado a ir até sua residência e indicou aos policiais militares onde estavam os entorpecentes dentro de sua residência (8,65 g de cocaína, 46,08 g de crack, 50,54 g de cocaína, e 815,94 g de maconha) e que estava guardando para um traficante em troca de porções de drogas. Relatou que guardava as drogas pois estava sendo ameaçado pelo traficante. Quanto aos 34 frascos de lança-perfume, disse os produzia e que também era para seu consumo. Disse que as balanças, plástico filme, papel alumínio, caderno e agenda lhe pertenciam (fls. 06 e 339/340).

Como se vê, o réu negou a prática do tráfico, disse que estava sendo ameaçado por

um traficante para guardar as drogas, que produzia os lança-perfumes para seu uso e que foi obrigado pelos policiais militares a ir até sua residência. No entanto, a versão apresentada pelo réu não merece credibilidade, pois está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furta da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada, como se verá doravante.

Com efeito, as testemunhas Alvaro Fioroto Junior e José Antônio Duarte Pinho, policiais militares, ouvidas em ambas as fases da persecução penal, relataram que avistaram três indivíduos parados em um terreno baldio e os abordaram. Em busca pessoal, o acusado Wesley carregava consigo 03 frascos de lança-perfume e 03 porções de maconha que segundo ele seriam para seu uso próprio. Com os dois adolescentes Luis e Renato, nada de ilícito foi encontrado. Idagado, o acusado informou que tinha armazenado em sua residência outras porções de entorpecentes. Na residência, autorizados pelo réu, entraram no imóvel. O acusado informou que em seu quarto havia outras substâncias, as quais posteriormente seriam fracionadas e vendidas. Foram localizados 52 eppendorfs com cocaína, 09 invólucros plásticos contendo maconha, 34 frascos contendo lança-perfume, 02 invólucros plásticos contendo cocaína, 01 invólucro plástico contendo crack, além de 02 balanças de precisão, plástico filme e diversos eppendorfs vazios (fls. 02, 03 e 339/340). Os policiais confirmaram que localizaram quantidade considerável de entorpecentes e que o réu confessou que iria comercializá-los.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

A testemunha Vania de Oliveira Lino Catuaba, mãe do acusado, ouvida em juízo, nada soube esclarecer sobre os fatos, limitando-se em tecer comentários sobre o réu e que não tinha envolvimento com drogas, que só cometeu este crime, pois estava sendo ameaçado (fls. 339/340).

Logo, tal depoimento não basta para comprovar a alegada coação moral irresistível, como se verá logo abaixo, lembrando que o ônus da prova do fato narrado na denúncia, em regra, é da acusação, no entanto, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal. No caso, a coação moral irresistível foi alegação da defesa.

As testemunhas Luis Gustavo Bomfim Rubim e Renato Messias Rodrigues de Moraes, ambos menores de idade, ouvidos somente na delegacia, relataram que são amigos do acusado Wesley, o qual tinha três lança-perfumes com ele e também um "baseado" que eles três iriam usar juntos. Nunca compraram droga do acusado e nunca souberam que ele vendia drogas. Na casa do acusado, encontraram mais drogas (fls. 04 e 05). Por outro lado, no que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consistem realmente em "maconha", "cocaína" e "lança-perfume" (exames químico-toxicológicos de fls. 133/147, 348/350 e 353/355).

De outra parte, a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, ou seja, 105,27g de cocaína, 826,09g de maconha e 37 frascos de lança-perfume; as circunstâncias da abordagem do réu (consumindo drogas com dois adolescentes); a apreensão de plástico filme, papel alumínio, balanças, eppendorfs vazios, caderneta e agenda com anotações do tráfico, e a confissão informal do réu aos policiais militares, estão a caracterizar a traficância.

No caso, não se pode olvidar que foram apreendidas duas balanças de precisão, eppendorfs vazios, plástico filme, papel alumínio, caderneta e agenda com anotações

do tráfico, juntamente com as drogas, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, estes apetrechos são utilizados para gerenciar e quantificar as porções que serão vendidas.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo e guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado trazer consigo e guardar os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

Neste ponto, irrelevante a alegação da defesa de que o réu estaria guardando a droga para terceira pessoa. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é chamado de tipo misto alternativo, possuindo vários núcleos, dentre eles trazer consigo e guardar, condutas essas efetivamente praticadas pelo acusado, mas que caracterizam crime único.

Por fim, é caso de se reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, porque restou demonstrada.

A prática do tráfico envolveu adolescentes, os quais sabiam que o réu estava com os entorpecentes, que inclusive consumiram juntos, o que se tornou corriqueiro no mundo do tráfico, em razão da condição de inimizabilidade a que os mesmos estão submetidos, sujeitos que estão ao Estatuto da Criança e Adolescente, cujas condutas não são, como é cediço, punidas com o mesmo rigor da lei penal.

Anoto que houve a mera omissão da capitulação jurídica dessa causa de aumento de pena na denúncia, mas isso não impede o magistrado de reconhecê-la na sentença, desde que o próprio fato conste expressamente naquela peça processual. Isso porque o réu se defende dos fatos, não da capitulação dada pelo órgão acusador.

É o caso dos autos. A denúncia descreveu expressamente o fato de o réu ter praticado o tráfico com os adolescentes Luis e Renato, razão pela qual deve ser reconhecida essa causa de aumento de pena, sem qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa, haja vista que o réu se defendeu desse fato.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo e guardava 826,09 gramas de maconha, 105,27 gramas de cocaína/crack e 37 frascos de lança-perfume, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Neste ponto, não prospera, como já acima exposto, a alegação do réu que teria agido mediante coação moral irresistível. Como se sabe, essa figura somente está presente quando a coação não poderia ser vencida ou superada pelo agente no caso concreto, o que não é caso dos autos. Frise-se, o réu não arrolou testemunha que comprovasse diretamente tal fato, tratando-se de alegação vazia, sem qualquer fundamento, no intuito de afastar sua responsabilidade penal. Por consequência, não há como se admitir a alegação defensiva de que o réu, quando guardava a droga em sua casa, tinha sua vontade comprometida.

Em outros termos, não há prova de que o réu estaria guardando a expressiva quantidade de maconha, cocaína e lança-perfume, por estar sendo ameaçado de morte. Lembre-se de que a única testemunha de defesa ouvida na instrução que mencionou tal fato foi sua mãe Vania, mas não deu maiores detalhes.

Ainda com relação à coação moral irresistível, anoto que o réu, em nenhum momento, relatou tal fato aos policiais militares que o prenderam, assim como na delegacia, nada mencionou sobre estar sendo ameaçado.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do

denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora a defesa tenha alegado que o acusado era usuário de drogas, tal alegação não restou comprovada, pelo contrário, foi afastada pelas provas colhidas durante a instrução, que confirmaram a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Ademais, a defesa, em um primeiro momento, pediu a realização do exame, mas depois dele desistiu após a audiência de instrução.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra conduta. Se o réu era viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Anote-se, ainda, que o acusado sequer assumiu a propriedade de parte da droga que estava em sua residência, alegando estar guardando para um traficante, o que afasta de vez a pretendida desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei de Drogas.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado não ostenta maus antecedentes, no entanto, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução de considerável quantidade de droga no mercado, se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-los com a sanção base mínima, tratando-os igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes. Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repreensão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154)

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como

não é possível "reformatio in pejus", a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277).

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (menor de 21 anos na data do fato) e retorno a pena ao seu patamar mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão, porque o réu alegou coação moral irresistível, procurando eximir-se de sua responsabilidade penal, lembrando que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, é aquela sem ressalvas, sem desculpas para o gesto criminoso, a qual não restou configurada no caso.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Não incide, no caso, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, porque a quantidade considerável de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada e ousadia por parte dos acusados, já que realizavam o tráfico em escala considerável, em sua própria casa, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, o que confirma a não incidência da causa de diminuição supracitada.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR WESLEY DIEGO LINO DUTRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 07/12/2021 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detracção penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de

pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastasse todos os argumentos expostos nos votos supracitados, no caso concreto, a substituição não é possível, porque a pena aplicada é superior a quatro anos, além do que o réu guardava considerável quantidade de entorpecente para entrega a consumo de terceiros (nada menos do que 826,09 gramas de maconha, 105,27 gramas de cocaína/crack e 37 frascos de lança-perfume), o que demonstra que o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime praticado. O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 94/96, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir, bem como aqueles expostos na decisão de fls. 277/278, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Por fim, anote-se que o réu guardava grande quantidade de drogas, o que traria efeitos altamente lesivos à sociedade e só vem confirmar a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública, lembrando que o acusado é reincidente em crime doloso.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do acusado, estão as



decisões proferidas nos Habeas Corpus impetrados em favor do acusado, que tiveram suas liminares indeferidas (fls. 120/121, 192/194 e 227/228) e, ao final, as ordens denegadas e não conhecida (fls. 452/457, 458/462 e 463/466), demonstrando o acerto deste Juízo na segregação cautelar do acusado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada às fls. 94/96, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Quanto aos objetos apreendidos (fls. 14/15), embora sejam instrumentos do tráfico de drogas, o certo é que, diante da natureza do objeto, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o a destruição dos objetos, instruindo-se o ofício com as cópias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA